

0001287-67.2017.8.26.0045

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de quatro anos, já foi processado por tráfico. Afirmou que quer falar a verdade, mencionou que já tomou um tiro pois tentaram roubá-lo, quando o rapaz apontou lhe a arma o depoente não teve coragem de olhar na cara dele, assim como que um cara fala que o reconhece com a arma apontada na face. Frisou que sua mãe já foi roubada e sabe o trauma que ela tem até hoje. Destacou que nenhuma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

0001287-67.2017.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001287-67.2017.8.26.0045

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON HENRIQUE DO CARMO TEIXEIRA SOUSA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

CLAYTON HENRIQUE DO CARMO TEIXEIRA SOUZA, EVANDRO CÉSAR SANTOS DE JESUS e MIROSMAR JOSÉ TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta de 20h30, na Rua Serra de Pacatuba, nº 282, nesta cidade e comarca de Arujá, os acusados, juntamente com outro indivíduo não identificado (de vulgo "Eeder Biriko"), agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra Eduarda Kauane Santos de Almeida, Otavio Benedito Domingos, Leandro de Oliveira Gonzalez e Danilo Cabral de Araujo, um celular Motorola, um celular Samsung, uma mochila, um boné, um forno elétrico, um notebook marca Acer, um home theater marca Toshiba e um narguilé de alumínio.

Narra a peça acusatória que na data dos fatos os acusados adentraram ao estabelecimento comercial tabacaria, pertencente a vítima Otavio Benedito Domingos, e abordaram as vítimas que ali se encontravam.

Evandro permaneceu no veículo Chevrolet Celta de cor prata, placa IOL 7022 utilizado para fuga após o roubo, enquanto o indivíduo não identificado (de vulgo "Edeer Biriko") permaneceu na porta fazendo a "segurança" durante o roubo, Clayton e Mirosmar, portando arma de fogo, adentraram no estabelecimento, anunciaram o assalto, renderam as vítimas que ali se encontravam e subtraíram um celular

Motorola da vítima Eduarda, um celular Samsung da vítima Leandro e uma mochila, um boné, um forno elétrico, um notebook marca Acer, um home theater marca Toshiba e um narguilé de alumínio da vítima Otavio, proprietário do estabelecimento. Evandro fora intimado a comparecer à delegacia de polícia e após tomar ciência sobre o fato que está sendo-lhe imputado, confessou a prática delitiva (fls. 134/137).

Boletim de ocorrência (fls. 13/15, 17/18, 19/21, 56/58 e 63/71). Termos de declarações e autos de reconhecimento (fls. 34/48). Folha de antecedentes (fls. 295/298).

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2019 (fls. 139/140).

Citado, o réu Clayton apresentou resposta à acusação (fls. 186/189), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 248/249).

O réu Evandro foi citado por edital (fls. 222/225).

Foi declarada extinta a punibilidade do réu Mirosmar José Teixeira e determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado Evandro César Santos de Jesus (fls. 248/249).

Em audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e interrogado o réu ao final (fls. 319/323).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva com a condenação do réu nos termos da denúncia, com aplicação do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal. Quanto à dosimetria da pena, pugnou pela exasperação da pena-base, ante as circunstâncias desfavoráveis e os maus antecedentes. Na segunda fase incide a agravante da reincidência. Na terceira fase, afirmou que estão presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, requerendo aumento maior da pena quanto ao concurso diante do número de agentes. Por fim há o aumento do concurso formal. Pugnou pela fixação do regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, sendo inviável a substituição por restritiva de direitos. A defesa do acusado apresentou alegações finais, argumentando a nulidade do reconhecimento fotográfico, pontuando que a vítima é induzida pelas fotografias havendo possibilidade de erro por falsas memórias. Apontou a ausência de provas suficientes para a condenação. Pugnou pela absolvição do réu (fls. 324/331).

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo restou comprovada pelo boletim de ocorrência e depoimentos orais colhidos na fase judicial.

A autoria delitiva, no entanto, é incerta.

Passo à análise da prova oral.

A vítima Otavio relatou que o estabelecimento era uma loja de narguilé, estavam todos do lado de fora, na calçada, quando chegaram os indivíduos armados, mandaram todo mundo entrar para dentro da loja. Comentou que recolheram celulares, dinheiro do caixa, narguilé, um aparelho de DVD e home theater, além de produtos como carvão e essência. Disse que não recorda da fisionomia, porém na época conseguiram fazer o reconhecimento pelas redes sociais. Mencionou que quando foram na delegacia levaram fotos deles e prints das redes sociais. Aduziu que fizeram o reconhecimento na delegacia, foi no dia seguinte, primeiro foi feito o BOPM e no dia seguinte fizeram o boletim na polícia civil. Contou que foi tudo muito rápido, menos de dez minutos, entraram três pessoas, um rapaz gordinho pardo, outro rapaz pardo e um moreno. Salientou que estavam com uma arma apenas, a princípio o moreno entrou armado, depois ele entregou o revólver para o rapaz gordinho que ficou na porta observando, os outros dois começaram a recolher as coisas. Afirmou que eles só mandavam ficar quietos, tentaram argumentar algumas vezes, depois que eles saíram baixaram a porta de aço e pediram para que ficassem dentro da loja. Externou que não estavam mascarados, estavam de cara limpa. Acrescentou que havia uma quarta pessoa num

veículo Celta que parou o veículo duas ruas para frente, o motorista ficou no carro e só desceram os três. Disse não recordar se na delegacia detalhou sobre a ação individual de cada um. Informou que a arma utilizada era um revólver calibre 38 cano curto. Frisou que na época reconheceu todos, tanto que pela placa do veículo eles foram chamados até a delegacia e um deles confessou o crime. Externou que foi atrás deles para pegar a placa e fez o contato com a polícia militar, os acompanhou até um bairro próximo. Observou que deu tempo de correr em casa que fica atrás da loja, pegou a chave e entrou no carro indo atrás do veículo Celta que o rapaz falou que tinha acabado de sair. Esclareceu que não presenciou os reconhecimentos das demais vítimas. Externou que quem conseguiu as fotos foi a Eduarda, ela tinha a foto de um deles ou alguém próximo a eles, então começaram a pesquisar e encontraram um por um. Apontou que Eduarda conhecia de festas de bairro, os conhecidos fluxos de rua, conheciam de vista, então começaram a pesquisar pessoas próximas do bairro que fizeram acompanhamento, era o Jardim Caiuby. Exaltou que foram fazendo as pesquisas e os encontraram, todos eles são amigos nas redes sociais, pesquisaram fotos, tinham fotos de um com o outro, até chegar a todos eles. Esclareceu que só o motorista não encontraram porque não chegaram a vê-lo, pois ele ficou o tempo todo no veículo, tanto que a princípio acharam que eram só três pessoas, e foi o que constou no boletim de ocorrência três pessoas, mas depois descobriram que tinha uma quarta pessoa. Destacou que a Eduarda achou um ou dois no Facebook ou Instagram, no dia seguinte sentaram todos na loja e reconheceram um a um. Disse não recordar dos nomes dos indivíduos. Observou que na delegacia foram umas duas ou três vezes para fazer o reconhecimento, apresentaram algumas identificações e aí sim na delegacia que efetuaram mais buscas. Complementou que na delegacia pesquisaram nas redes sociais também, família, até encontrar todos eles e foram informados que um deles foi intimado a prestar esclarecimentos e até assumiu a autoria do crime. Apontou que os réus não foram apresentados e o reconhecimento foi somente por foto. Mencionou que perdeu o contato com o carro já no bairro Caiuby, na rua Cuiabá. Apontou que no tempo de fuga dos criminosos já abriram a porta da loja de esquina, o Leandro ficou observando eles que saíam pelo lado esquerdo, o depoente correu para sua casa e pegou o carro, mais ou menos 200 metros, na esquina, eles pegaram o carro e saíram, o depoente foi no acompanhamento deles.

Ao efetuar o reconhecimento pessoal a vítima disse que não tem absoluta certeza, tem a semelhança de fisionomia, mas está mais magro.

A vítima Leandro relatou que estavam numa tabacaria, o depoente estava sentado do lado de fora, na porta, quando chegaram quatro indivíduos abordando-os, pedindo que entrassem, os colocaram no fundo e foram pegando bens materiais do estabelecimento e bens pessoais de cada um. Detalhou que de características, tinha um rapaz alto, outro moreno, e um mais gordo. Afirmou que chegaram quatro indivíduos, abordaram primeiro o depoente, apontando o revólver e mandando que entrassem. Externou que eles estavam de cara limpa, só um com uma blusa de frio e capuz na cabeça. Pontuou que na época dava sim para identificá-los, na delegacia apresentaram fotos deles e na época foi fácil de reconhecer. Noticiou que conversaram entre si, a Eduarda achou o perfil da rede social de um deles, e ao conversar confirmaram que era um deles. Informou que pelo o que se lembra não acharam outros. Disse que passaram as informações aos investigadores e delegado, lembra que lá eles mostraram algumas fotos e confirmaram que eram eles, desde então só teve informação que um dos indivíduos se apresentou. Revelou que o reconhecimento foi feito por foto e havia uma foto de cada um. Informou que no dia foi subtraído seu aparelho celular. Contou que foi rápido, eles baixaram a porta, fizeram o recolhimento, um deles chamou o depoente para levantar a porta e abaixar de novo, em seguida escutaram barulho de porta de carro e saíram. Complementou que entraram no carro e seguiram o carro em que eles estavam, informaram a placa do veículo no 190.

Ao efetuar o reconhecimento pessoal a vítima disse não recordar nitidamente porque está bem diferente.

A vítima Danilo disse que estava atrás do balcão, chegaram uns caras falando que era assalto, pensou que era brincadeira, mas olhou direito e o rapaz veio apontando a arma, então se assustou. Aduziu que um rapaz meio gordinho foi e abaixou a porta,

ficou todo mundo lá dentro e o outro ficou recolhendo as coisas, os objetos, mercadorias, dinheiro e celular. Disse lembrar mais ou menos das características, um era branco, forte e gordinho, outro era com pele mais escura, ele entrou com a arma na mão depois ele a deu para o outro, tinha mais um, mas não se lembra dele direito.

O réu Clayton disse que tem 27 anos, trabalha como anunciante de internet, ganhava por venda, estudou até a quinta série, é casado e tem um filho de quatro anos, já foi processado por tráfico. Afirmou que quer falar a verdade, mencionou que já tomou um tiro pois tentaram roubá-lo, quando o rapaz apontou lhe a arma o depoente não teve coragem de olhar na cara dele, assim como que um cara fala que o reconhece com a arma apontada na face. Frisou que sua mãe já foi roubada e sabe o trauma que ela tem até hoje. Destacou que nenhuma das suas passagens é sobre arma, não usa arma de fogo, tem quatro casas de aluguel e duas casas na praia, pois quando seu pai morreu deixou uma renda boa para não precisar viver do crime. Assumiu que é usuário de maconha e cocaína, mas não precisa roubar. Pontuou que seu filho passa por psicólogo e o depoente foi difamado na rede social como ladrão, que é onde vem o seu sustento. Apontou que tem problema de chagas e bronquite asmática, jamais entraria numa tabacaria para correr risco de saúde. Exclamou que dentro do presídio já está quase morrendo, não iria roubar um home theater e um narguilé, dos quais não faz uso. Declarou que se quisesse um home theater tem dinheiro para pagar à vista e não roubar dos outros, porque o que os outros tem é com muito suor. Mencionou que queria pedir para ele ter consciência sobre o que estava fazendo, pois estava julgando um inocente, se fosse mesmo o que roubou não iria mentir, assumiria com o maior prazer do mundo, porque seu pai fez um homem. Disse que não quer ser condenado mais uma vez por algo que não fez, porque é uma injustiça. Frisou que jamais uma pessoa sob a mira de arma de fogo iria reparar na sua cicatriz.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ao cabo da instrução processual verifica-se a fragilidade probatória, sendo insuficiente a embasar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia. Ainda que as vítimas tenham realizado o reconhecimento fotográfico em solo policial, quando parte delas foi ouvida em Juízo e submetidas ao reconhecimento pessoal, não foram capazes de confirmar o reconhecimento anterior, não sendo admitida a condenação tão somente com base nos elementos colhidos no inquérito policial ante a ausência de exercício do contraditório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim é que malgrado o relato das vítimas acerca dos fatos em análise tenha sido minucioso e rico em detalhes, é de se observar que o feito carece de prova robusta acerca da autoria do réu Clayton.

De fato a prova oral dá conta de que as vítimas saíram no percalço dos réus após o cometimento do delito, sendo também mencionado que os assaltantes estavam com o rosto à mostra e que após os fatos as vítimas lograram êxito em reconhecer os réus, localizando-os nas pesquisas efetuadas pelas redes sociais.

Contudo, mesmo que tais circunstâncias sugiram a participação do réu no delito em tela, ante a falta de reconhecimento expresso e diante da possibilidade de ser o roubador pessoa distinta do réu, não há como proferir um édito condenatório.

Isto porque, a prova dos autos é lacunosa, e falha ao indicar com segurança que o réu Clayton tenha de fato praticado o delito que lhe fora imputado, embasando-se a pretendida condenação no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em solo policial.

Ocorre que tal reconhecimento feito extrajudicialmente, sem participação da defesa e sem preenchimento dos requisitos do artigo 226 do CPP carece de força probante. Ainda que as vítimas tenham "reconhecido" o réu por meio das imagens, é preciso ter em conta que tal certeza é uma condição subjetiva que não se transmite automaticamente aos destinatários da prova, que são o juiz e as partes.

Dito de outro modo, o fato de a vítima ter certeza sobre quem reconhece não significa que o juiz e as partes também tenham essa certeza. Não se transmite a condição subjetiva do ofendido para os demais. Isso ocorre porque aquele que é vítima de fatos violentos, automaticamente e aqui isso de fato é automático sofre

descargas bioquímicas que podem alterar a sua percepção sobre a realidade vivenciada, fazendo com que possa conservar, desde então, memórias alteradas. Em termos investigativos, trata-se o reconhecimento de prova que deve ser analisada em conjunto com os demais elementos produzidos nos autos, como quais deve estar em harmonia, o que não ocorreu no caso dos autos, não passando despercebidas as falhas no procedimento adotado.

O que a vítima ou a testemunha diz sobre o fato não é necessariamente a verdade real, mas sim uma representação que guarda sobre o fato. Pode ser uma representação muito próxima ou muito distante do que realmente ocorreu, havendo risco de se tratar de falsas memórias.

Nesse passo, destaco recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, conduzido por um paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº598.886 SC, julgado em 27.10.2020), no qual afirma que "o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva".

A propósito:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das conseqüências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às

formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão – SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à

participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC - RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Obviamente não se está afirmando que as vítimas faltaram com a verdade. Apenas se considerando a possibilidade de erro, que não seria incomum neste tipo de prova. Aliás, como oportunamente destaca Gustavo Badaró, "o reconhecimento pessoal já foi apontado como a mais falha e precária das provas. A principal causa de erro no reconhecimento é a semelhança entre as pessoas." (2016, p.483).

Também sobre o reconhecimento, destaca Fernando da Costa Tourinho Filho: "O reconhecimento é, de todas as provas, a mais falha, a mais precária. A ação do tempo, o disfarce, as más condições de observação, os erros por semelhança, a vontade de reconhecer tudo, torna o reconhecimento uma prova altamente precária". (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, ed.14ª, Ed. Saraiva, São Paulo: 2011, p. 622).

A respeito do valor do reconhecimento como prova, Guilherme de Souza Nucci também esclarece: O juiz jamais deve condenar uma pessoa única e tão-somente com base no reconhecimento feito pela vítima, por exemplo, salvo se essa identificação vier acompanhada de um depoimento seguro e convincente prestado pelo próprio ofendido, não demovido por outras evidências. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2008, p. 500).

Além do mais, cabe frisar novamente que as três vítimas, Otavio, Leandro e Danilo, ao efetuar o reconhecimento pessoal em Juízo, não reconheceram o réu com plena certeza.

Insta ressaltar, neste escopo, que a peça chave do caso, a vítima Eduarda, não chegou a ser ouvida em Juízo, mesmo sendo ela quem teria supostamente localizado os réus pelas contas das redes sociais, inviabilizando a confirmação dela acerca de tais fatos.

Nessa mesma esteira, não se ignora que ao depor em Juízo a vítima Leandro terminou por contradizer a afirmação da vítima Otávio de que todos os réus teriam sido localizados pelas redes sociais, tendo dito Leandro que um deles foi localizado apenas.

Assim, não é possível descartar que o réu poderia ser um dentre os demais indivíduos que não foram reconhecidos pelas redes sociais ou mesmo que sequer teria tido participação no delito em tela, sendo associado ao caso por alguma semelhança de imagem do perfil da sobredita rede social.

E quanto à pesquisa sobre o perfil dos réus nas redes sociais, com a localização dos prints de imagens deles, embora se verifique a sua ocorrência às fls. 04, certo é que as imagens dos autos estão muito pouco nítidas, dificultando a comparação com a imagem do réu Clayton que consta na mídia da audiência.

Em acréscimo, conquanto os réus tenham prosseguido no encalço dos roubadores após a ocorrência do assalto, conforme relatado por Otavio e Leandro, e localizado o veículo Chevrolet Celta de cor prata, placa IOL 7022, ao que se observa não se demonstrou vínculo entre todos os assaltantes e o proprietário do veículo.

Pontua-se que conforme relatório policial o veículo estaria em nome de Josefa Cristina Santos de Jesus, e na pesquisa de identificação civil efetuada pela polícia consta que era ela genitora de Evandro César dos Santos de Jesus, inexistindo aparente ligação de qualquer um dos dois com o réu Clayton.

E quanto a Evandro César Santos de Jesus, suposto envolvido no delito em tela, por sua vez, quando ouvido em solo policial e admitiu sua participação, afirmou que foi procurado por dois indivíduos denominados Bruninho e Rafinha, tendo praticado o roubo conjuntamente com eles.

Ocorre que tais nomes não condizem com o do réu Clayton e, ademais disso, as fotos

que representam tais indivíduos e que constam às fls. 07, 10 e 12 do relatório de investigação, do mesmo modo, estão muito pouco nítidas, não se verificando, sem sombras de dúvidas que alguma delas retrataria o averiguado do feito.

O réu, por sua vez, negou com veemência o cometimento do delito. E embora sua versão não seja necessariamente digna de absoluta credibilidade, ante o histórico pessoal desfavorável (fls. 295/298), não merece ser necessariamente descartada. Assim, como já referido, não há como impor a condenação ao réu Clayton, haja vista que não foi devidamente reconhecido em Juízo pelas vítimas, e, ao que se tem notícia, nem tampouco foi apreendido em poder de qualquer produto do crime ou de eventual armamento, o que poderia levar à conclusão de eventual participação na empreitada criminosa relatada na denúncia.

Neste sentido foi o entendimento do E. Tribunal de Justiça em caso muito semelhante ao dos autos, senão vejamos:

Apelação. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Reconhecimento do réu na Delegacia de Polícia que se deu por meio fotográfico, precedido pelo envio de fotografias de suspeitos via Whatsapp. Em juízo, foram descumpridas as regras previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Acusado que não foi preso em flagrante delito. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição que se impõe. Apelo provido. (TJSP - 1500137-06.2019.8.26.0045 - Desembargador Relator Leme Garcia - 06 de junho de 2022).

Diante de tal quadro, levando-se em conta a carência probatória e ainda que restam dúvidas quanto a quem de fato teria praticado o roubo, impõe-se a absolvição no caso em tela.

Registre-se que ao réu não incumbe a prova de sua inocência, sendo do Ministério Público o ônus de comprovar, de maneira robusta, a sua culpabilidade.

Forçoso, in casu, verificar que, não havendo qualquer outra prova que confirme a prática do crime descrito na denúncia pelo réu, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado, de modo a permitir que este seja absolvido da imputação que lhe fora direcionada.

Como se vê, os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com um mínimo de segurança que o acusado efetivamente praticou o crime em tela, visto que o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.178/19):

...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos.

Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo.

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma

condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

Isto posto e por tudo mais que dos autos costa, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu CLAYTON HENRIQUE DO CARMO TEIXEIRA SOUZA, qualificado nos autos, das imputações que lhes foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários aos patronos nomeados pela OAB/DPE.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, indevida a condenação do réu ao pagamento das custas finais, haja vista que não foi condenado. P.I.C.

Aruja, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA